

NUR KAMILAH BINTI ZAKARIA

lawan

MOHAMAD ARIF ABDUL RAZIQ BIN SAIMIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 11hb September 2020 / 23 Muharram 1442H

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0064-2020

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : Ahmad Fuad Syafwan bin Mohamad Amin dari Tetuan Nooraizan & Partners.

Pegum Syarie Responden : -

Permohonan

[1] Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut :

- i. Mahkamah menyemak prosiding dan keputusan kes Permohonan no. 10300-038-0114-2020, di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 30/6/2020 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;
- ii. Mahkamah membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Permohonan no. 10300-038-0114-2020 bertarikh 30/6/2020 dan mengeluarkan Perintah memberikan hak jagaan anak bernama INDAH NURMARYAM ARISSA BINTI MOHAMAD ARIF

ABDUL RAZIQ (No mykid :190831-10-2316) selepas ini dikenali sebagai “anak tersebut” kepada Pemohon beserta hak akses yang wajar kepada Responden;

- iii. Lain-lain perintah yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah yang Mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden adalah bekas suami isteri. Hasil perkahwinan, telah memperolehi seorang anak yang bernama Indah Nurmaryam Arissa Binti Mohamad Arif Abdul Raziq (No mykid :190831-10-2316), selepas ini dikenali sebagai “anak tersebut”.

[3] Pemohon telah memfailkan satu permohonan Perintah Interim Hak Jagaan Anak secara *inter-parte* pada 13/2/2020 melalui kes no. 10300-038-0113-2020 dan juga kes induk tuntutan jagaan anak melalui saman no. 10300-028-0113-2020.

[4] Pada 30/6/2020, Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa hak jagaan sementara diberikan kepada Responden dan Pemohon diberikan hak untuk melawat dan berjumpa dan bermalam dengan anak tersebut pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan dengan diambil pada hari Jumaat jam 8.00 malam dan dihantar pulang pada hari Ahad sebelum jam 7.00 petang.

[5] Pemohon telah menfailkan permohonan semakan berkaitan perintah Mahkamah bertarikh 30/6/2020 tersebut dengan alasan antaranya bahawa:-

- i. Responden telah mengambil anak tersebut sebelum perintah dikeluarkan dan Pemohon telah dinafikan hak untuk berjumpa dan mengambil anak tersebut semula. Sedangkan menurut Pemohon anak tersebut masih kecil iaitu berumur 10 bulan ketika keputusan dikeluarkan oleh Hakim Bicara.
- ii. Hakim Bicara terkhilaf apabila memutuskan hak jagaan sementara kepada Responden sedangkan anak tersebut masih kecil dan menyusu badan. Pemohon juga menyatakan anak tersebut sejak dilahirkan memang tidak pernah berpisah dengan Pemohon kerana Pemohon dan Responden bercerai sebelum anak tersebut dilahirkan lagi.
- iii. Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak mengaplikasikan dengan sewajarnya seksyen 84 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas **keputusan/perintah** Hakim Bicara pada 30/6/2020. Alasan Pemohon adalah kerana perintah Hakim Bicara adalah silap memandangkan umur anak tersebut di bawah 2 tahun yang perlu diletakkan di bawah jagaan ibu iaitu Pemohon.

[7] Sesuatu permohonan semakan yang dikemukakan ke Mahkamah Rayuan Syariah adalah dibuat berdasarkan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Sebelum sesuatu permohonan semakan dibenarkan, adalah perlu dipastikan terlebih dahulu sama ada kes-kes tersebut sesuai atau tidak untuk dibuat proses semakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] –

Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah telah menggariskan panduan bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak. Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Lihat kes *Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah [2013]JH36(2)*, *Sa'diah binti Hj. Tamin lwn Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015]JH41(2)*, *Jamaludin bin Che Murad lwn Dasmawati [2017]JH44(2)* dan *Maya binti Ahmad Fuaad lwn Hisham bin Halim [2018]JH46(2)*.

[8] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah Permohonan Semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara atau perintah/penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Permohonan no. 10300-038-0114-2020, iaitu kes permohonan Hak Jagaan Anak Sementara secara *inter-parte* yang difailkan oleh Pemohon pada 13/2/2020. Di dalam afidavit sokongannya, Pemohon mendeposkan bahawa anak tersebut adalah berumur 10 bulan ketika perintah Hakim Bicara tersebut dibuat pada 30/6/2020. Pemohon menyatakan Hakim Bicara telah tersilap dari segi hukum Syarak dan undang-undang apabila tidak mengambil kira umur anak tersebut ketika memerintahkan anak tersebut diberikan kepada Responden.

[10] Kami mendapati bahawa di dalam kes ini, Notis Permohon dan Affidavit Sokongan, Affidavit Jawapan Affidavit Balasan dan Hujah telah pun difailkan oleh pihak-pihak. Kami juga mengambil maklum fakta bahawa anak yang menjadi subjek pertikaian adalah berumur di bawah umur 2 tahun yang sepatutnya dijaga oleh ibu berdasarkan hukum Syarak dan seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[11] Bagi anak yang belum mumaiyiz, maka ia adalah tertakluk kepada '*status quo*' undang-undang berdasarkan seksyen 82 Enakmen di mana ibu adalah pihak yang paling berhak terhadap hak penjagaan anak kecil (belum mumaiyiz) dan hak ini diberikan kepada ibu tersebut apabila ia memenuhi syarat kelayakan sepertimana yang dinyatakan pada peruntukan seksyen 83 EUUKIS 2003. *Status quo* ini juga telah diulas oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor sebagai anggapan undang-undang di dalam kes Abdul Malek Bin Abdul Kadir lwn. Zulzilawati Binti Jusoh, Kes Rayuan (Selangor) No. : 10000-028-0084-2016 sepertimana berikut -

“Anggapan ini telah memberikan kedudukan yang positif kepada Responden sebagai ibu kepada anak tersebut. Namun demikian anggapan ini boleh dipatahkan jika isu ketidaklayakan seseorang penjaga dibawah seksyen 84 dapat dibuktikan. Dalam hal ini, Perayu sebagai Defendan telah mempertikaikan kelayakan Responden sebagai Penjaga dalam pembelaannya. Oleh itu beban tersebut perlulah ditanggung oleh Perayu berdasarkan seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor 2003...”

[12] Kami bersetuju bahawa Hakim Bicara telah khilaf meneliti isu sebenar bagaimana anak tersebut telah terpisah dengan Pemohon dan keadaan pada masa-masa material yang berpanjangan tidak pernah terpisah dengan Pemohon

selaku ibu kandungnya semenjak kelahiran anak tersebut pada 31/8/2019 iaitu selepas perceraian Pemohon dan Responden. Pemohon sebagai seorang ibu yang mempunyai taraf *status-quo* hadhanah dan merupakan orang yang paling layak untuk menjadi hadhinah kepada anak perempuan yang berusia bawah 2 tahun dari segi undang-undang dan hukum Syarak.

[13] Dalam hal ini juga, kami berpendapat Hakim Bicara seharusnya berhati-hati dalam memutuskan kes yang berkaitan kebajikan anak yang masih kecil. Dengan merujuk kepada firman Allah swt di dalam surah al-Baqarah ayat 233, yang mana Ayat 233 tersebut adalah sebagai panduan yang paling penting dalam membuat keputusan dalam menentukan hak jagaan yang berusia dalam lingkungan dua (2) tahun dan masih menyusu badan. Firman Allah tersebut berbunyi:-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَ أَيْتِمٍ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {233}

Maksudnya:-

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

[14] Berdasarkan ayat 233 surah al-Baqarah tersebut maka dapat difahami bahawa menyusukan anak itu adalah suatu tuntutan/perintah dari Allah swt di mana ianya adalah merupakan suatu “hak dan kebajikan” bagi anak tersebut. Apabila berlakunya penghalangan terhadap “hak dan kebajikan” anak tersebut dari mendapat penyusuan ibunya, ini bererti hak dan kebajikan anak tersebut tidak dipelihara.

[15] Merujuk kepada hadis Rasulullah saw juga dalam riwayat Abu Daud (2276), al-Baihaqi (15763) dalam *Fiqh Al Islami Waadillatuh*, Jilid 10, *Darul Fikir al Maasir*, halaman 8299, Abdullah bin `Amr meriwayatkan bahawa ketika mana datang seorang wanita lalu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَبْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي
وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Maksudnya:

Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya (tinggal sewaktu mengandung), puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah pelindungnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum bernikah.”

[16] Kami berpendapat adalah perlu untuk kami campurtangan dalam perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara pada 30/6/2020. Demi kebajikan anak

tersebut, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Kedua-dua pihak masih mempunyai hak untuk membangkitkan apa-apa fakta berkaitan dalam kes permohonan hak jagaan induk yang masih dalam prosiding. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-

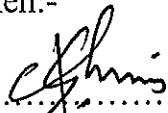
1. Permohonan semakan Pemohon diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah pada 30/6/2020 dalam kes no. 10300-038-0114-2020 adalah dibatalkan.
3. Mahkamah dengan ini memerintahkan **secara sementara** seperti berikut-
 - i. Hak Jagaan anak yang bernama Indah Nurmaryam Arissa Binti Mohamad Arif Abdul Raziq (No Mykid :190831-10-2316) ("*anak tersebut*") diberikan kepada Pemohon (ibu).
 - ii. Hak lawatan, bersama dan bermalam bagi anak tersebut diberikan kepada Responden (bapa) pada pada minggu pertama dan ketiga dengan diambil pada hari jumaat jam 8.00 malam dan dihantar pulang pada hari Ahad sebelum jam 6.00 petang.
 - iii. Pengambilan dan penghantaran anak tersebut adalah ditempat dimana anak tersebut tinggal atau mana-mana tempat lain yang dipersetujui oleh Pemohon dan Responden.
4. Perintah-perintah ini berkuatkuasa serta merta sehingga tuntutan kes induk hak jagaan anak no. 028-0113-2020 didengar dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor